

1500279-41.2021.8.26.0400

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... a efetiva prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), equiparado ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 1º, da LD) ou de tráfico ilícito de maquinismos relacionados ao processamento de drogas (art. 34, caput, da LD).

Daí ser desnecessário apreender a droga ou examiná-la.

Valho-me, pois, dessa explicação.

Nos termos do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1500279-41.2021.8.26.0400 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500279-41.2021.8.26.0400

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

WEMYSSON SILVA e outro

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Wemysson Silva e Vítor Manoel Silva, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) e art. 35, caput, da LD (fls. 130/132).

Determinou-se o processamento (fls. 142/145).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 167 e 169), apresentou resposta escrita (fls. 181/183). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2021 (fls. 253/255) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 306 e 308).

II - DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é, em parte, procedente.

Certa a materialidade objetiva de um dos contextos fáticos descritos na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 31/33 [B0]), do auto de exibição e apreensão (fls. 34 [AEA]) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 36/38) e definitivo (fls. 288/289 [LPTox]), ressalvado o elemento subjetivo (dolo), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue, com ressalva, a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha Lucas Aughusto Lopes, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 04), que: "estávamos realizando patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistamos um veículo parati de cor prata, visto que já era de conhecimento este veículo estar envolvido em ação criminosa, bem como tínhamos a informação de quem um possível foragido da justiça estava se locomovendo com este veículo, logo vimos um indivíduo sozinho no banco de trás tentando se esconder, já achamos atitude suspeita, demos sinal de parada e verbalização; realizamos busca pessoal em ambos indivíduos, o que estava na condução e o que estava no banco de trás, porém nada de ilícito foi localizado, realizamos busca veicular, e localizamos debaixo do banco dianteiro direito quinze porções de maconha; indagados, Vítor confirmou ser de sua propriedade o entorpecente, e o condutor do veículo Wemysson Silva, informou que não sabia da droga e que estaria indo para casa guardar o carro; diante dos fatos demos voz de prisão em flagrante, e conduzimos até o plantão policial." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Rafael Henrique Pissinin de Souza, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03), que: "estávamos realizando patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistamos um veículo parati de cor prata, visto que já era de conhecimento este veículo estar envolvido em ação criminosa, bem como tínhamos a informação de quem um possível foragido da justiça estava se locomovendo com este veículo, logo vimos um indivíduo sozinho no banco de trás tentando se esconder, já achamos atitude suspeita, demos sinal de parada e verbalização; realizamos busca pessoal em ambos indivíduos, o que estava na condução e o que estava no banco de trás, porém nada de ilícito foi localizado, realizamos busca veicular, e localizamos debaixo do banco dianteiro direito quinze porções de maconha; indagados, Vítor confirmou ser de sua propriedade o entorpecente, e o condutor do veículo Wemysson Silva, informou que não sabia da droga e que estaria indo para casa guardar o carro; diante dos fatos demos voz de prisão em flagrante, e conduzimos até o plantão policial." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

O informante Wilson Silva, que é irmão dos acusados, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Por ouvir dizer, os seus irmãos foram abordados pela Polícia Militar. Dirigiu-se, por isso, ao lugar dos fatos. Relatou, em síntese, os antecedentes, a conduta social e a personalidade dos acusados."

A testemunha Everaldo Manoel dos Santos, que é amigo dos acusados, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Por ouvir dizer, os seus

amigos foram abordados pela Polícia Militar. Dirigiu-se, por isso, ao lugar dos fatos. Relatou, em síntese, os antecedentes, a conduta social e a personalidade dos acusados."

* Sr. Vítor Manoel Silva:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 14).

Negou a prática criminosa.

Negou, igualmente, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, saiu para comprar, para consumo pessoal, drogas (maconha), o que foi feito. Era viciado em drogas. Ao retornar, encontrou-se com o seu irmão (coacusado). Ele estava de carro. Pegou carona com ele. Sentou-se no banco traseiro. No caminho à residência da senhora sua mãe, os membros da Polícia Militar ordenaram a parada, o que foi feito. Nessa hora, dispensou as drogas sob o banco dianteiro. Abordaram-nos. Em busca veicular, os agentes do Estado localizaram as drogas. O seu irmão desconhecia a existência das drogas. Conduziram-nos à Delegacia de Polícia. Não alegou nada pessoal contra os membros da Polícia Militar inquiridos."

* Sr. Wemysson Silva:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 05).

Negou a prática criminosa.

Negou, igualmente, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, saiu para ir à residência da senhora sua mãe, quando, no caminho, encontrou-se com o seu irmão (coacusado). Ele pediu-lhe carona. Ele sentou-se no banco traseiro, pois a porta da frente estava danificada (sic). No caminho, os membros da Polícia Militar ordenaram a parada, o que foi feito. Abordaram-nos. Em busca veicular, os agentes do Estado localizaram as drogas. Desconhecia a existência das drogas. O seu irmão confirmou a propriedade das drogas. Conduziram-nos à Delegacia de Polícia. Não alegou nada pessoal contra os membros da Polícia Militar inquiridos."

Pois bem.

Em capítulos distintos, disserto.

2.1.1Do acusado Vítor Manoel Silva

No entender deste magistrado, sem modificar a descrição do contexto fático contido na denúncia, atribuo, nos termos do art. 383, caput, do CPP, definição jurídica diversa (art. 28, caput, da LD).

E, assim, delibero sobre o contexto fático descrito na inicial.

Nos termos do art. 28, caput, da LD, "quem adquirir, guardar, 'ter' em depósito, transportar ou 'trazer' consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", configura a infração penal de porte ilícito de drogas para consumo pessoal.

O tipo penal, vejam, é "adquirir" (obter; comprar; aquisitar), "guardar" (vigiar; vigilar; conservar; manter), "ter em depósito" (pôr em depósito; armazenar; guardar [em lugar seguro]; dar a guardar temporariamente), "transportar" (conduzir; levar

de um lugar para outro; enlevar; arrebatado; transpor) ou "trazer consigo" (conduzir ou transportar para cá; fazer-se acompanhar), "para consumo pessoal" (elemento subjetivo específico), "drogas" (as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União [art. 2º da LD]) "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (elemento normativo).

A redação do art. 28, caput, da LD, diferentemente do disposto no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), descreve elemento subjetivo específico do tipo.

Por se tratar de infração permanente (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/04), entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 313 do CPP).

Das dezoito condutas descritas no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), o art. 28, caput, da LD (porte ilícito de drogas para consumo pessoal) descreve cinco idênticas (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo).

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), ou alheio (art. 33, caput, da LD), o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama da parte ré (odioso critério subjetivo) (STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não são excludentes, consigno, os tipos penais relativos ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) e ao porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 14).

A coincidência das figuras é comum (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 08).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação do fato constitutivo do direito do autor da ação penal (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) incumbe ao Ministério Público (Parquet) – ou querelante – e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500406-47.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI, V.U., j. 06/06/2022, p. 05).

E, nesse ponto, o Parquet, posto perquirir, não comprovou.

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face do acusado Vítor Manoel Silva pela prática do contexto fático previsto no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ – 5ª Turma – AgRg no HC n. 300.212/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ – 5ª Turma – HC n. 286.582/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ – 5ª Turma – HC n. 353.232/MG – Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

Regularmente periciadas (LPTox), as drogas localizadas e apreendidas são proscritas pela Portaria MS/SVS n. 344/1998 – Anexo Lista E, item 1 (CANNABIS SATIVUM [planta que pode originar substância entorpecente ou psicotrópica], conhecida popularmente por maconha).

No entender deste magistrado, o contexto fático conhecido e provado (o acusado, por ocasião dos fatos, trazia consigo drogas indevidamente) não autoriza, por indução, concluir-se pelo elemento subjetivo descrito na denúncia (vontade de participar da produção e da circulação de drogas [intuito mercantilista]), o que caracterizaria o crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD).

Trata-se de dado elementar duvidoso.

Nessa perspectiva, os agentes de segurança pública, os quais têm o meu respeito e consideração, não trouxeram, ao serem inquiridos em Juízo, dados suficientes de que as drogas, no caso vertente, destinavam-se ao consumo alheio (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005997-69.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. IVO DE ALMEIDA, V.U., j. 20/05/2019; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000163-02.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MIGUEL MARQUES E SILVA, V.U., j. 7/06/2018; TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003239-20.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. NEWTON NEVES, V.U., j. 08/08/2019).

Ao contrário, há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente a existência da infração penal de porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), seja pela observação forense do que ordinariamente acontece (quod plerunque accidit), seja pelas circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos).

Assim, convenço-me que o acusado Vítor Manoel Silva, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, trazia consigo, para consumo pessoal, as drogas apreendidas (AEA), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

De rigor, pois, a desclassificação criminal.

Eis o meu convencimento.

2.1.2Do acusado Wemysson Silva

Nos termos do art. 33, caput, da LD, "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

O tipo penal, vejam, é "importar" (fazer vir; trazer, introduzir mercadorias de outro País), "exportar" (enviar, remeter, vender para fora do País ou do Estado), "remeter" (mandar; enviar; recomendar; fazer entrega; expedir; encaminhar; destinar), "preparar" (aprontar; arranjar; obter [um corpo qualquer] por meio de composição ou decomposição; compor; dosear; urdir; maquinar; pôr em condições de servir; predispor), "produzir" (dar origem a; causar; fabricar), "fabricar" (produzir na fábrica; manufaturar, preparar; inventar; engendrar), "adquirir" (obter; comprar; aquisitar), "vender" (alienar; ceder por certo preço; trocar por dinheiro; negociar; não conceder gratuitamente; sacrificar por dinheiro ou por interesse; entregar mediante remuneração; dispor do que possui a troco de dinheiro), "expor à venda" (apresentar; mostrar), "oferecer" (dar; facultar; levar à presença de; mostrar), "ter em depósito" (pôr em depósito; armazenar; guardar [em lugar seguro]; dar a guardar temporariamente), "transportar" (conduzir; levar de um lugar para outro; enlevar; arrebatado; transpor), "trazer consigo" (conduzir ou transportar para cá; fazer-se acompanhar), "guardar" (vigiar; vigilar; conservar; manter), "prescrever" (receitar; ministrar), "ministrar" (prestar; fornecer; aplicar), "entregar" (dar; ceder; confiar) "a consumo" (elemento subjetivo específico [pela interpretação contextual]) ou "fornecer" (promover; abastecer; garantir; ministrar; proporcionar ou ministrar o necessário a) "drogas" (as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União [art. 2º da LD]), "ainda que gratuitamente" (animus sine lucro captando), "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (elemento normativo).

A redação do art. 33, caput, da LD, diferentemente do disposto nos arts. 28, caput (porte ilícito de drogas para consumo pessoal), e 33, § 1º, III (utilização ilícita de bem para o tráfico ilícito de drogas ou com o seu consentimento), da LD, não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 4.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. BACILA, Carlos Roberto; RANGEL, Paulo. Comentários penais e processuais penais à lei de drogas. – 1.ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007. MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legislação penal especial. 7.ª edição – São Paulo: Atlas, 2004. MARCÃO, Renato. Tóxicos: lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 – nova lei de drogas. – 4.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2007. JESUS, Damásio de. Lei antidrogas anotada – comentários à lei n. 11.343/2006. – 9.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2009. GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice, CUNHA, Rogério Sanches, OLIVEIRA, William Terra de. Lei de drogas comentada. 3.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008), referendado pela jurisprudência (STF – Primeira Turma – Habeas Corpus 69.806-GO – Rel. Min. Celso de Mello, DJ, Seção I, 04/06/1993; STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 03; TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 – Rel. Des. Paulo Rossi, V.U., j. 20/06/2011; TJGO – ACrim. n. 33578-9/213 – Rel. Des. Jamil Pereira de Macedo, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), de que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, exige-se a vontade de participar da produção e da circulação de drogas (a intenção de comercializar drogas ilícitas).

Não se exige, todavia, a exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002166-76.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 21/08/2019, p. 11).

Por se tratar de infração permanente (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/04), entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 313 do CPP).

Das dezoito condutas descritas no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), o art. 28, caput, da LD (porte ilícito de drogas para consumo pessoal) descreve cinco idênticas (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo).

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), ou alheio (art. 33, caput, da LD), o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama da parte ré (odioso critério subjetivo) (STJ - Sexta Turma - AREsp 1.790.656-SC - Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética - 3. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 - São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não são excludentes, consigno, os tipos penais relativos ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) e ao porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 14).

A coincidência das figuras é comum (TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 08).

"Existe a possibilidade de critério para se imaginar a justeza de uma guerra. Talvez se dissesse que, na guerra contra o tráfico, na guerra contra a bandidagem, na guerra contra a corrupção, aí, sim, há uma justeza porque a causa é nobre" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética - 3. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 - São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 106).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação do fato constitutivo do direito do autor da ação penal (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) incumbe ao Ministério Público (Parquet) - ou querelante - e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua.

E, nesse aspecto, o Parquet, posto perquirir, não provou.

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face do coacusado Wemysson Silva pela prática do contexto fático previsto no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ - 5ª Turma - AgRg no HC n. 300.212/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ - 5ª Turma - HC n. 286.582/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ - 5ª Turma - HC n. 353.232/MG - Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

O quadro de provas produzido não é bastante (suficiente).

Não existe prova suficiente do nexo de causalidade entre o contexto fático descrito na denúncia e aquele testemunhado em Juízo, de um lado, e, de outro, os objetos do crime processado e julgado (ou seja, as drogas localizadas e apreendidas), pontífico.

De rigor, pois, a absolvição (art. 386, VII, do CPP).

Eis o meu convencimento.

2.1.3 Da associação para o tráfico ilícito de drogas

Nos termos do art. 35, caput, da LD, "associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 'da Lei de Drogas'", configura o crime de associação para o tráfico ilícito de drogas.

O tipo penal, vejam, é "associarem-se" (reunirem-se, juntarem-se, com ânimo de associação, de caráter duradouro e estável) "duas ou mais pessoas" (plurissubjetividade) "para o fim de praticar" (elemento subjetivo específico [finalidade associativa]), "reiteradamente ou não" (habitualidade ou eventualidade executiva), "qualquer dos crimes" apontados com taxatividade pela Lei de Drogas (finalidade associativa).

O que diferencia o crime de associação criminosa específica do tráfico ilícito de drogas (art. 35, caput, da LD) do concurso de pessoas (art. 29 do CP) é o elemento subjetivo (animus) dos sujeitos ativos do crime.

Exige-se, para a configuração do crime de associação criminosa, a demonstração concreta do vínculo de estabilidade e permanência (associatividade), diferentemente do concurso de pessoas.

Não é suficiente a união ocasional, eventual e episódica.

Para determinar se a reunião era, ou não, eventual, o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias comportamentais dos sujeitos ativos do crime (critério objetivo), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama dos sujeitos ativos (odioso critério subjetivo) (STJ - Sexta Turma - AREsp 1.790.656-SC - Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04)

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética - 3. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 - São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não se exige, para a configuração deste crime autônomo, a efetiva prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), equiparado ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 1º, da LD) ou de tráfico ilícito de maquinismos relacionados ao processamento de drogas (art. 34, caput, da LD).

Daí ser desnecessário apreender a droga ou examiná-la.

Valho-me, pois, dessa explicação.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação do fato constitutivo do direito do autor da ação penal (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto

criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) incumbe ao Ministério Público (Parquet) – ou querelante – e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500406-47.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI, V.U., j. 06/06/2022, p. 05).

E, nesse aspecto, o Parquet, posto perquirir, não provou.

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face dos acusados pela prática do contexto fático previsto no art. 35, caput, da LD (associação para o tráfico ilícito de drogas), consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ – 5ª Turma – AgRg no HC n. 300.212/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ – 5ª Turma – HC n. 286.582/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ – 5ª Turma – HC n. 353.232/MG – Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

O quadro de provas produzido não é bastante (suficiente).

No presente caso dos autos, não há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente o caráter associativo da convergência de vontades (animus manendi, intenção de permanecer, ânimo associativo) de se praticar um número indefinido de crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.U., j. 22/01/2020, p. 06), como, por exemplo (verbi gratia), a habitualidade do contato dos acusados (periodicidade), a confluência dos diálogos (correspondência) e o conteúdo das comunicações (thema).

Não existe prova suficiente (bastante, necessária) de que se tratava de reunião estável e permanente (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0003398-60.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. PÉRICLES PIZA, V.U., j. 12/08/2019, p. 11).

Nesse aspecto, a denúncia, em relação ao contexto fático, é retrospectiva (aspecto subjetivo), mas, em relação às provas, é prospectiva (fonte [aspecto objetivo]) (TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0004887-69.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO, V.U., j. 12/06/2022, p. 12 [... os elementos colhidos a esse título autorizam a condenação do agente, porque os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo."]) e, desse modo, o contato (interação) dos acusados, em que pese a relação familiar de coabitação (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1501130-17.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.U., j. 10/05/2021, p. 06/07 [... nada se investigou sobre mais do que a coautoria, não sendo bastante a mera suspeita de associação permanente, ainda que se tome em consideração o fato de os dois estarem praticando o tráfico de drogas no âmbito familiar."]), era meramente ocasional ou episódico.

Não era um verdadeiro pacto associativo, acerto.

Não está evidente a intenção de reiteração delituosa.

Descaracterizada, pois, a associação criminosa específica.

De rigor, pois, a absolvição (art. 386, VII, do CPP).

Eis o meu convencimento.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, sem modificá-la (art. 383 do CPP), adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 28, caput, da LD.

Consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União (art. 1º, parágrafo único, da LD).

Em outras palavras, dependência – física ou psicológica – é o estado de quem não consegue desligar de um hábito, especialmente de um vício (prejudicialidade).

Por se tratar de conduta que compromete os elementos do dolo – cognitivo ou intelectual [representação] e volitivo – (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001193-87.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO CARUSO COSTABILE E SOLIMENE, V.U., j. 02/09/2019, p. 13/14), a clara ofensividade (gravidade) e periculosidade da conduta, independentemente da quantidade da droga, impedem, por assim reconhecer (STF – 2ª Turma – HC 115.246/MG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28/05/2013), a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (porte ilícito de drogas para consumo pessoal), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407], secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, da parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas, LD), não cominou pena privativa de liberdade para o crime de porte ou cultivo ilícitos de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput e § 1º, da LD), cujo preceito secundário passou a cominar medidas educativas (novatio legis in melius).

As medidas educativas, atendendo-se aos critérios dos arts. 42 da LD e 59 do CP (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e a Defesa.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto infracional processado e julgado – Porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28 da LD): I – advertência sobre os efeitos das drogas; II – prestação de serviços à comunidade; III – comparecimento a programa ou curso educativo –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da

Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Não há registros criminais (fls. 294/298), verifico.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, as circunstâncias não são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a medida-base em advertência sobre os efeitos das drogas.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, não observo nenhuma, de modo que fixo a medida provisória nos exatos termos da base penal.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a medida provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP e art. 27 da LD, fixo a MEDIDA DEFINITIVA em advertência sobre os efeitos das drogas.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de (1.) desclassificar, com fundamento no art. 383, caput, do CPP, o contexto fático denunciado (art. 33, caput, da LD) e, por ser competente para o julgamento, condenar, com fundamento nos arts. 383 e 387, caput, do CPP, a parte ré VÍTOR MANOEL SILVA, portadora do RG n. 62.246.384 – SSP/SP, como incursa no art. 28, caput, da LD, à medida educativa de advertência sobre os efeitos das drogas; (2.) absolver, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, a parte acusada WEMYSSON SILVA, portadora do RG n. 56.916.868 – SSP/SP, da prática do contexto fático denunciado (art. 33, caput, da LD), pois não existe prova suficiente para a condenação; e (3.) por fim, absolvê-las, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, da prática do outro contexto fático denunciado (art. 35, caput, da LD), pois não existe prova suficiente para a condenação; conseqüentemente (art. 386, parágrafo único, II, do CPP), ordeno a cessação das medidas cautelares (ad cautelam) e provisoriamente aplicadas (art. 282, § 5º, do CPP).

3.1 Das providências preliminares

Dispensada, conseqüentemente, a expedição de guia de recolhimento definitiva em desfavor da parte ré (art. 472, I, das NJCGJ).

3.2 Das custas processuais

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003.

3.3 Da pena de multa

Não há cominação.

3.4 Das comunicações

Comunique-se, por meio eletrônico (iirgd.dipol@policiacivil.sp.gov.br), diretamente ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) (art. 809, VI [sentenças de mérito], do CPP e arts. 393, V, e 472, I, das NJCGJ [Comunicado CG n. 464/2019]), que se incumbirá da remessa aos demais órgãos competentes para efetivação.

Registrada eletronicamente (art. 389 do CPP e art. 72, §§ 4º e 6º, das NJCGJ).
Publicada em audiência (art. 389 do CPP). Intimadas as partes em audiência (arts.
390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NJCGJ). Oportunamente,
arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 24 de agosto de 2022.

Eduardo Luiz de Abreu Costa
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)